

1501101-78.2019.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes contra a Fauna
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/11/2022
... 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Insurgência contra suposta violação ilegal de domicílio. Inocorrência. Elementos de prova a indicarem que o ingresso foi escorado em fundadas suspeitas de que lá se praticava crime, com confirmação decorrente da apreensão de considerável quantidade de drogas para o tráfico, segundo confissão. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501101-78.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501101-78.2019.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Fauna
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO CESAR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

JULIO CESAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 12 e 16, parágrafo 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, no artigo 29, caput, da Lei nº 9.605/98 c.c. os artigos 14 e 29, ambos do Código Penal, no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 e no artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, porque, no dia 23 de março de 2019, por volta de 14 horas, no sítio São Francisco, situado na estrada Paratinga, nº 108, neste município, possuía em sua residência uma arma de fogo espingarda, de marca Berreta, calibre 24, com número 42699, de uso permitido, bem como duas munições de calibre 24, de uso permitido, e também uma arma de fogo espingarda, de calibre 36, com numeração suprimida, todas sem

autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço já descritas, o acusado tinha em cativeiro oito espécimes da fauna silvestre nativa, sem autorização para tal.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço já descritas, o acusado concorreu para que seus dois netos adolescentes iniciassem a execução de caça de espécimes da fauna silvestre nativa, sem autorização para tal, somente não consumando a conduta por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço já descritas, o acusado facilitou a corrupção de duas pessoas menores de dezoito anos de idade, induzindo-as a praticarem infração penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

A Defesa, em seus memoriais, pugnou pela procedência parcial da ação, com a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 e sua absolvição quanto aos demais delitos. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial realizado nas armas e nas munições, pelo laudo pericial relativo às aves apreendidas, bem como pelos demais elementos constantes dos autos.

A autoria quanto a estes crimes também é certa.

A testemunha policial militar ambiental Erick Oliveira Santana, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava patrulhamento pela região do Paratinga quando visualizou dois rapazes utilizando uma armadilha do tipo arapuca. Disse que, questionados, ambos informaram que a armadilha destinava-se à caça de juritis e, indagados sobre suas residências, ambos indicaram um sítio próximo, de seu avô, a poucos metros daquele local. Esclareceu que não havia nenhuma ave capturada com os adolescentes. Disse que, no sítio indicado, foi feito contato com o acusado e sua esposa. Consignou que, de pronto, avistou gaiolas contendo aves nativas e, questionado, o réu disse serem de sua propriedade, informando haver outras naquele local. Declarou que o réu franqueou a entrada da equipe e acompanhou a busca realizada, durante a qual, foram localizadas mais espécimes nativos, além de armas de fogo do tipo espingardas e munições, e também mais armadilhas e utensílios para a caça de aves. Esclareceu que juriti é uma espécie de ave nativa e não recordou se havia esta espécie em gaiola. Consignou que as gaiolas contendo aves nativas, que estavam na parede externa do imóvel, podiam ser vistas do lado de fora do sítio, e,

dentro do imóvel, também foi encontrada gaiola com ave nativa. Relatou que as armas e as munições foram localizadas em um mesmo cômodo dentro da residência. Esclareceu que uma das armas possuía numeração e não recordou se os armamentos estavam muniçados. Disse que, dentre as munições apreendidas, havia cartuchos deflagrados e intactos. Declarou que, quanto à arma numerada e às aves apreendidas, o acusado não apresentou qualquer documentação. Disse não recordar se havia ave morta em algum local do sítio e esclareceu que, em um freezer, havia um animal abatido, que o réu, informalmente, disse tratar-se de uma ave nativa. Relatou que, também informalmente, o acusado confirmou a prática de caça de aves, mas não recordou se ele forneceu esclarecimentos sobre auxílio prestado pelos menores para essa atividade.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar ambiental Paulo Galvão Nogueira, também ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento pela estrada do Paratinga quando viu dois adolescentes à beira da estrada, montando uma armadilha para caça, mas não havia nenhuma ave capturada com eles. Disse que, abordados, ambos declararam que estavam no sítio do avô, próximo àquele local. Declarou que foi ao sítio, onde o réu recepcionou a equipe. Disse que a casa estava toda aberta e ali estavam a esposa do réu e outros parentes. Relatou que o local possuía uma área externa com varanda onde havia gaiolas com espécimes nativos e, em análise aos animais, verificou que eles não ostentavam anilhas. Narrou que, acompanhado pelo réu a todo o momento, constatou que dentro da residência também havia gaiola com espécime nativo, em relação ao qual o réu também não possuía licença. Disse que, em um dos quartos da residência, foram localizadas espingardas, que não recordou se estavam muniçadas, e relatou que o acusado apresentou também munições, que não recordou estarem intactas ou deflagradas. Questionado sobre as armas, o réu disse, informalmente, que também não possuía autorização para tê-las e que as usava para caça. Narrou que, no freezer da casa, havia pedaços de carne já cortados para consumo, que verificou ser de juriti ou outra subespécie também nativa, distinta de ave cuja comercialização é permitida. Consignou que não foram encontrados juritis nas gaiolas do sítio, esclarecendo que esta espécie não se adapta ao cativeiro. Declarou que, ao abordar os adolescentes, pode notar que o acusado os incentivava aos atos de caça e constatou que, no sítio, havia uma armadilha semelhante àquela que os adolescentes foram vistos usar.

A testemunha de defesa Fernando José de Castro disse ser amigo do acusado, pois residiu por pouco mais de três anos em um sítio ao lado daquele em que morava o réu. Declarou que, próximo ao imóvel onde residia o acusado, havia entre quatro ou cinco sítios. Relatou que não possuía arma de fogo e desconhecia a posse por outros residentes daquela região. Declarou que não ouviu sons de disparos de arma de fogo. Disse que juriti é uma ave comum àquela região, mas desconhecia haver caça de tal animal, desconhecendo, também, que o réu ou seus netos realizassem caça de aves.

A testemunha de defesa Rinaldo Menezes Maia disse possuir uma propriedade vizinha àquela em que o acusado trabalha como caseiro, conhecendo-o há cerca de três a quatro anos. Declarou ser comum proprietários de sítios possuírem arma de fogo e soube por um dos proprietários que ele o faz para manter a segurança do local e da família, ante a inconstância do policiamento. Disse que não presenciou atos de caça no local e nunca viu o acusado fazê-lo, consignando que já se fez necessário retirar pessoas de sua propriedade que lá estavam sob o argumento de que caçariam. Narrou que possui criação de animais em seu sítio e que, no sítio onde reside o réu, há criação de animais como porcos, galinhas, frangos, coelhos, patos, gansos, peixes e outros, sendo em grande parte pertencente ao patrão do réu e destinada ao consumo. Disse que juriti é uma espécie de pombo comum naquela região e declarou que o acusado não precisa caçar para alimentar-se.

Interrogado em Juízo, ao final, o acusado admitiu que tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, negando a prática dos demais delitos descritos na denúncia. Disse que as armas e as munições apreendidas foram deixadas em sua casa

pelo antigo caseiro do sítio, que ali havia residido e que havia dito que retornaria para buscá-las, mas nunca o fez. Alegou que não deu qualquer destinação aos armamentos e munições, porque não eram seus e porque tinha receio de manuseá-los, sendo que eles estavam guardados em um quarto que permanecia fechado, mas, na data dos fatos, estava aberto, por ter buscado equipamentos naquele cômodo. Disse que as aves encontradas eram suas e as havia adquirido há muitos anos em um comércio de ração, sendo que as criava por ser um hobby. Contou que não incentivou seus netos a caçarem aves silvestres e estes, quando o visitavam, usavam estilingues ou arapucas, que eram materiais precários feitos por eles, por conta própria. Alegou que, após os fatos, seus netos, que tinham 16 e 17 anos de idade, lhe disseram ter sido agredidos por um dos policiais que os abordaram. Contou que, no local dos fatos, havia gaiolas com os pássaros dos quais cuidava e também uma armadilha, porém esta estava quebrada e não era usada para caça. Disse que a ave encontrada em seu freezer tratava-se de galinha, de espécie criada no sítio, e não de um juriti, pois não usa esta ave em sua alimentação. Declarou que permanece trabalhando no mesmo local, onde há criação de gansos, galinhas, patos, marrecos, cabritos, porcos e peixes.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado quanto aos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 descritos na denúncia, diante das provas produzidas.

A palavra dos policiais que, de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como se deu, inicialmente, a abordagem dos adolescentes e, posteriormente, a localização das aves nativas em cativeiro e das armas e munições não restou abalada.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu “é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se “imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento” (TJSP – AP – Rel. Walter Guilherme – j. 10.03.98 – JTJ 214/284).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos dos policiais militares, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial e a localização das aves em cativeiro, bem como das armas de fogo e das munições, e encontram-se em verdadeira consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial.

As testemunhas bem esclareceram em Juízo a dinâmica de toda a ação policial, pormenorizando como se deu a abordagem dos adolescentes, que verificaram ser parentes do acusado, e, em seguida, como ocorreu a busca no sítio do acusado, autorizada por este, onde foram localizadas aves nativas em cativeiro, bem como as duas armas de fogo e as duas munições intactas.

Afirmaram as testemunhas policiais que, pelo lado de fora do sítio, era possível ver gaiolas que estavam na parede externa do imóvel e que continham aves nativas. Consignaram que, autorizada a entrada pelo réu no imóvel, verificou-se que ali havia mais gaiolas com espécimes nativos e, em um dos cômodos, havia as armas e munições.

Veja-se que o próprio acusado admitiu ter as aves apreendidas em cativeiro, alegando, entretanto, que as havia adquirido em um comércio de rações.

Da mesma forma, admitiu que, em sua residência, estavam os armamentos e as munições apreendidos, alegando, quanto a estes, não serem de sua propriedade, mas, sim, do anterior caseiro, que ali havia residido.

Contudo, sua versão quanto às armas e às munições restou absolutamente isolada no contexto probatório.

O acusado não apresentou qualquer esclarecimento sobre quem seria o caseiro anterior que teria residido em seu imóvel e não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que demonstrasse que as armas pertenciam àquele.

Note-se, ao contrário, que as testemunhas arroladas pela Defesa declararam conhecer o acusado há mais de três anos, do local em que ele reside, nada mencionando sobre o anterior caseiro do sítio.

Não é crível, portanto, a alegação do réu de que optou por permanecer por longo período com os armamentos e as munições em um dos cômodos de sua casa - cômodo este que era por ele utilizado, vez que admitiu que o quarto estava aberto na data dos fatos porque de lá havia retirado material para seu uso -, apenas aguardando o retorno do anterior caseiro - cuja identificação sequer foi trazida pela Defesa - para buscá-los ou mesmo porque ele temesse o manuseio de armas.

Assim, não restam dúvidas de que os oito espécimes da fauna silvestre nativa mantidos em cativeiro e as armas de fogo e as munições apreendidas pertenciam ao acusado.

A junção de todos estes elementos de prova traz a certeza necessária para um decreto condenatório quanto aos delitos previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei

nº 9.605/98.

A eficácia e a potencialidade lesiva das armas de fogo e das duas munições intactas apreendidas foram atestadas pelo laudo pericial de fls. 69/78.

Verifica-se que os dois cartuchos íntegros de calibre 24 estavam realmente aptos para a realização do disparo, tendo sido, inclusive, utilizados para o exame de eficiência da arma de fogo de mesmo calibre apreendida.

Veja-se, ainda, que a arma de fogo de calibre 26 tinha seu número de identificação suprimido e este somente foi revelado por utilização de método específico durante a perícia realizada, observando-se que a numeração foi "interpretada" pelo Perito Relator como sendo "A750".

Não há dúvidas de que o armamento efetivamente estava com o número - que poderia identificá-lo de forma conclusiva - suprimido.

Saliente-se, ainda, que não haveria como ser reconhecida eventual causa supralegal excludente de ilicitude quanto à posse das armas de fogo para manutenção da segurança do sítio ou da família do acusado.

Observando-se que a atualidade do perigo é um dos requisitos da excludente de ilicitude do estado de necessidade, não houve qualquer prova de qualquer ameaça que estivesse sofrendo.

De qualquer forma, não se deve olvidar que, quem pretender portar arma a fim de defender-se, só pode assim proceder mediante autorização da autoridade competente.

Quanto às oito aves apreendidas, o laudo pericial de fls. 102/104, aliado à informação de fls. 102/104, concluiu serem animais pertencentes à fauna silvestre.

Da mesma forma, não apresentou o acusado qualquer licença, permissão ou autorização de autoridade competente para manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre.

Finalmente, não há se cogitar em nulidade da prova por "invasão a domicílio" cometida pelos policiais.

Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, visto que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

É a hipótese do crime de possuir armas e munições e do crime de ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, ambos de natureza permanente e que têm sua consumação protraída no tempo. A entrada dos policiais era justificada pela situação de flagrância constatada.

Note-se que, no presente caso, havia a fundada suspeita da prática dos aludidos crimes no local dos fatos. Confira-se:

Como evidenciado pela prova amealhada aos autos, a diligência realizada no sítio do acusado ocorreu após os policiais abordarem dois adolescentes, que estavam em posse de uma armadilha para caça. Ambos informaram que tinham a intenção de caçar juritis e indicaram residir no sítio de seu avô, para onde os policiais se deslocaram e avistaram os animais da fauna silvestre. Portanto, a busca ali realizada não ocorreu de forma aleatória.

Ressalte-se que a testemunha Erick afirmou que, de fora do imóvel, já era possível avistar as gaiolas contendo as aves nativas, tendo sido a diligência dentro do imóvel, que culminou com a apreensão das aves nativas e das armas de fogo e das munições, permitida pelo acusado.

Não se pode alegar, portanto, qualquer tipo de conduta abusiva por parte dos policiais ao entrarem na residência do acusado, nem que tenham agido de forma aleatória, repita-se.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

Transcreve-se, a seguir, a mencionada tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"HABEAS CORPUS - Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida - Preliminar - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO - Presente in casu a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão pelos policiais sem mandado judicial. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. Precedente do STF. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP - IMPOSSIBILIDADE - A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, arma de fogo e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2140716-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI N. 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) - PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DE DOMÍLIO - Não há nulidade por violação de domicílio quando o policial adentra à casa do acusado, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada a situação de flagrante (art. 5º, XI, da CF), notadamente em se tratando de crime de natureza permanente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA E POSSE

IRREGULAR DE MUNIÇÃO - Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos. REDUÇÃO DA PENA-BASE - Possibilidade. Dolo normal ao tipo. Penas redimensionadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME - Impossibilidade. Deve ser mantido o regime prisional fechado para o crime de reclusão e semiaberto para o apenado com detenção. Tanta a quantidade de drogas e munições apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. PREQUESTIONAMENTO - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso da defesa parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1525924-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Insurgência contra suposta violação ilegal de domicílio. Inocorrência. Elementos de prova a indicarem que o ingresso foi escorado em fundadas suspeitas de que lá se praticava crime, com confirmação decorrente da apreensão de considerável quantidade de drogas para o tráfico, segundo confissão. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado, com fundamentação inidônea. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as reprimendas de PEDRO a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e de ALEXANDRE a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. " (TJSP; Apelação Criminal 0003609-60.2020.8.26.0302; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como as autoridades devem assim proceder Não se vislumbra qualquer exceção à atuação de guardas municipais, integrantes dos quadros de força pública no âmbito municipal -Prova ilícita em razão de invasão de domicílio Não cabimento Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão (...)(TJ-SP - APR: 15014712820208260599 SP 1501471-28.2020.8.26.0599, Relator:Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 21/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:21/06/2021)

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de ilicitude probatória nos procedimentos que cercaram a prisão em flagrante consiste na violação do domicílio sem prévia investigação ou ordem judicial. Liminar deferida. 1. Ilicitude probatória não configurada. Intervenção policial que, a princípio, foi motivada pelo quadro de justa causa. Ação motivada por denúncia anônima que indicou o endereço e a pessoa responsável pelo armazenamento das drogas. Uma vez no local, os policiais avistaram o paciente que ao notar a aproximação da viatura correu para o interior do imóvel que havia sido referido na denúncia. Ilegalidade que não se mostra evidente. Necessidade de aprofundamento da questão ao longo da instrução. 2.

Fumus commissi delicti dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Visibilidade e imediatidade da prática delituosa. Quadro de justa causa configurado. 3. Não demonstração do periculum libertatis. Quantidade de drogas pequena. Paciente primário. A ausência de comprovante de ocupação lícita não é, no caso dos autos, elemento suficiente a justificar a imposição da medida extrema. Ausência de elementos indicativos da gravidade concreta. Precedentes. 4. Medida extrema que se apresenta desproporcional. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 22255992520208260000 SP 2225599-25.2020.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 16/10/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020)

O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça adota esse entendimento, conforme recentes decisões:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protraí-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. 2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência". 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º,

LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína. 5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." (RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo que se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. III - No caso, ao desobedecer o sinal de parada dado pela Guarda Municipal, o agravante se evadiu e foi perseguido por 15 km até ser interceptado. Admitindo ser foragido da Justiça Pública, o agente, que não portava documentos de identificação, foi conduzido até a sua residência, local onde foram encontrados mais de 9,278 kg de cocaína e tambor contendo lidocaína, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do

ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada a pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

Assim, restou demonstrada a autoria do acusado quanto aos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

De outra banda, de rigor sua absolvição quanto aos crimes tipificados no artigo 29, caput, da Lei nº 9.605/98 c.c. os artigos 14 e 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

Não há demonstração efetiva de que o acusado tenha concorrido, de qualquer forma, para que os adolescentes iniciassem a execução de caça de espécimes de fauna silvestre ou nativa.

Inferre-se da prova amealhada que os adolescentes abordados pelos policiais militares, embora estivessem na posse de uma armadilha, não haviam caçado nenhum espécime.

Em que pese aos relatos das testemunhas policiais de que os adolescentes, informalmente, disseram que caçariam juritis, não houve demonstração de que a armadilha destinava-se realmente à caça de tais animais.

Nenhuma ave desta espécie foi também apreendida no sítio onde os adolescentes estavam residindo.

Nem mesmo se poderia afirmar que algum juriti já teria sido caçado, seja pelos adolescentes, seja pelo réu.

Observe-se que nem mesmo houve conclusão pericial (fls. 194/198) de que o material congelado encontrado no freezer da residência do réu fosse proveniente de algum espécime da fauna silvestre nativa.

Da mesma forma, não há como se afirmar que as oito aves apreendidas na residência do acusado tenham sido caçadas por meio de armadilhas, seja pelo réu ou pelos adolescentes.

Ressalte-se que a apreensão de armadilhas, com os adolescentes ou na residência do réu, sem a efetiva demonstração de que estas se destinavam à captura de algum animal da fauna silvestre, não é apta, isoladamente, para configurar o crime descrito no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, ainda que em sua forma tentada.

Por consequência lógica, não restou demonstrada a prática do crime tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Procedente em parte a denúncia, passo, a dosar a pena.

1. Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras razões para fixação da pena-base acima de seu mínimo legal, ficando fixada em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na última fase do cálculo da pena, observo que não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

2. Quanto ao delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras razões para fixação da pena-base acima de seu mínimo legal, ficando fixada em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na última fase do cálculo da pena, observo que não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

3. Quanto ao delito tipificado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras razões para fixação da pena-base acima de seu mínimo legal, ficando fixada em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas e, mesmo reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea quanto a este delito, esta não tem o condão de diminuir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual fica a pena inalterada nesta fase.

Na última fase do cálculo da pena, observo que não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

As penas dos crimes deverão ser somadas de acordo com as regras do concurso material de delitos, resultando, quanto aos crimes previstos nos artigos 12 da Lei nº 10.826/03 e 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, apenados com detenção, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa relativa ao crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Considerando a somatória total de penas, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena (LEP, art. 111).

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, diante do montante de pena imposta. Também pelos mesmos motivos, é incabível o sursis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu JULIO CESAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por incurso nos artigos 12 da Lei nº 10.826/03 e 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, e às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, devendo as penas ser

somadas nos termos do disposto no artigo 69 do Código Penal, e, diante da somatória total, em conformidade com o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, fica estabelecido o regime semiaberto para início do cumprimento de pena;

2. ABSOLVER o réu JULIO CESAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita de ter praticado os delitos previstos nos artigos 29, caput, da Lei nº 9.605/98 c.c. os artigos 14 e 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Indefiro o pedido para a extração de cópias dos autos e remessa à Polícia Civil para instauração de inquérito, na forma requerida pelo Ministério Público, uma vez que a Constituição Federal não recepcionou a primeira parte do inciso II do artigo 5º do Código de Processo Penal.

Evidentemente, sob pena de se perder a imprescindível imparcialidade inerente ao juiz, não pode ele deliberar sobre a opinio delicti (cuja titularidade foi entregue pela Constituição Federal de 1988 ao Ministério Público) requisitando a instauração de inquérito policial, indiscutivelmente uma atividade persecutória.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POR FORÇA DE REQUISIÇÃO DO JUIZ. INC. II DO ART. 5º DO CPP NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

1. Não pode o juiz investigar, função própria da autoridade policial, não pode e não deve, também, requisitar abertura de inquérito policial. A primeira parte do inciso II do art. 5º do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal, que alçou o sistema acusatório à sua posição máxima, ao entregar tão-só ao Ministério Público a função de acusar, como se pode observar da leitura do art. 129, VIII, da Constituição Federal. Nemo iudex sine actore (Não há juiz sem autor) ou ne procedat iudex ex officio (o juiz não pode proceder sem provocação da parte). 2. O juiz não pode e não deve deliberar sobre a opinio delicti (opinião, ponto de vista sobre o delito). Há a perda da imprescindível imparcialidade do juiz ao deliberar sobre a opinio delicti, requisitando a instauração de inquérito policial, por tratar-se de uma atividade persecutória. 3. No presente caso, no entanto, o juiz que requisitou o inquérito não vai presidir o processo, haja vista que foi dele afastado. A proibição de o juiz requisitar o inquérito é para preservar sua imparcialidade." (TRF, 1ª Região, HC 64844 MT 2009.01.00.064844-9, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ TOURINHO NETO, Julgamento em 23 de Novembro de 2009, Publicação em 04/12/2009 e-DJF1 p.214)

Dessa forma, caberá ao próprio Ministério Público providenciar o necessário para a concretização de seu requerimento.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 24 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA